建设用地指标法律属性的重释与厘定*

汪　莉**

内容摘要:建设用地指标市场化改革在实践中广泛进行,基于建设用地指标行政配置僵化和市场在土地资源配置中作用彰显的现实,需要对其法律属性加以重释。目前,学界围绕建设用地指标法律属性这一基础性理论命题的论证,"私权说"和"公权说"皆有之,呈现出混乱与片面的态势,亟需正本清源。从社会现实出发,建设用地指标既是国家重要的土地调控工具,既具有公权力的外在表现,又表现出私权利外观。其法律属性需要对二者兼容,将其定位于公私权融合属性,在理念上符合公私权合作理念,在规范上贴合政策法规的精神,在实践上切合现实发展需求。并以此为依据对土地用途管制权等公权力设置合理限制,对土地发展权的私权属性予以立法规范。

关键词:建设用地指标　法律属性　公权力　私权利

DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2022.04.010

一、研究缘起

建设用地需求与耕地保护之间存在长期矛盾,国家利用建设用地指标制度管理和调控建设用地。1998年修订的《土地管理法》确立土地用途管制制度,利用指标的指令性管控,有效遏制了建设用地无序扩张,对我国土地资源的保护起到了重要作用。但随着社会主义市场经济的不断发展,依靠行政调控手段的指标管理制度难以适应实践需求。部分经济发展较快地区出现指标不够用情况,欠发达地区却存在着指标滥用情况,且制度文本与实践效果相去甚远,违法转用土地的事件屡禁不止,指标管理机制出现失灵。① 随着"市场在资源配置中起决定性作用"这一改革理念的明确与深化,探索指标制度的市场化显得十分之必要。实践中出现了诸如"折抵指标有偿调剂""宅基地置换""城乡建设用地增减挂钩"及"地票"等多种类型指标市场化探索。这些实践模式存在或多或少的缺陷,但均一定程度缓解了指标行政配置的僵化。指标市场化改革成为趋势。

指标制度改革不断深化,但指标的法律属性却一直没有得以明确。指标法律属性的模糊,严重影响其背后制度的体系化构建和有效运行。传统行政管制下的指标仅从公法角度加以解读,一般被理解为土地用途管制工具。但随着指标市场化进程的推进,指标的私法属性进一步彰显。公法与私法的碰撞与融合,公权力与私权利的交汇与合作是指标的时代特征。因此,从法学角度对指标属性加以解读,廓清其乱象,还原其本源,是明确指标制度建设的理论前提与逻辑起点,亦是对实践需求的积极回应。是故,本文试图对指标的法律属性作出详细分析,进而作出明确定义,为指标制度的建设贡献绵薄之力。

二、建设用地指标法律属性重释的现实需求

无论是指标单一行政管制之时,还是指标开始市场化探索之后,指标的法律属性均处于模糊混乱状态。梳理指标的现实脉络,以确定其现实需求,是重释指标法律属性的基础。

* 本文系国家社会科学基金一般项目"土地功能区分视角下农地权利配置的理论反思和体系重构研究"(项目编号:17BFX111)、安徽大学文科创新团队建设项目(农村产权改革相关重大法律问题研究)的阶段性成果。

** 上海大学法学院教授,上海市锦天城律师事务所律师,安徽大学安徽法治与社会安全研究中心研究员。

① 参见郭洁:《土地用途管制模式的立法转变》,载《法学研究》2013年第2期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（一）建设用地指标行政配置僵化

土地利用规划对指标作出预设，利用土地利用总体规划设定控制指标，对建设用地总量和耕地保有量作出规划，利用土地利用年度计划设定年度指标，按年度对新增建设用地及耕地占补平衡作出控制。在运行过程中，指标由中央政府通过指令性计划层层分配给地方政府，地方制度实施土地开发行为必须拥有相应的新增指标且完成耕地占补平衡任务。但是指标在单一的行政管制措施中出现僵化。

指标行政的僵化主要表现为行政权力的法治化程度不够：一方面，在设定土地利用规划时，其编制、审批主体均是特定的行政主体，根据《土地管理法》的规定，省级以上人民政府的土地行政主管部门拥有本辖区建设用地总体规模的确定权、农用地转用审批权以及土地利用总体规划的制定权，《城乡规划法》进一步确定了省、市、县各级人民政府编制并审批土地利用规划的权力。② 且《土地管理法》忽略了规划制定者法律责任的相关规定，权责不对等是造成土地规划在制定伊始就出现纰漏。土地规划封闭运行出现问题，由于土地市场的垄断性，信息的真实性得不到保证，且受土地财政和政绩考核等因素的影响，地方政府既是土地规划的执行者，又是土地市场的经营者，可能会瞒报谎报实情，中央政府获得土地市场信息可能是扭曲的、失真的。且政府是有限的理性主体，为了实现特定政治目标的手段，在抉择的过程中可能缺乏甚至人为地忽略了规划对社会发展的信息回馈。另外一方面，指标的分解下达表现出行政强制性。土地规划指标的分配往往遵循“量”的平均原则，以保持所谓不同区域的“发展权利公平”和减少政府内部的矛盾。③ 由强制性规定和禁止性规定严格控制指标的实际使用，在进行土地出让前需要按照控制性详细规划对具体项目进行一一核验，对土地开发全过程进行管控，并依据土地督查制度对违反规划控制的用地行为进行严格的惩治。且指标的审批权较为集中，目前，凡是涉及用地的项目，无论是否符合规划，都要经过行政审批。而我国目前土地的审批权力集中在中央和省级政府，市、县政府的审批权限非常小。造成项目用地审批的繁琐，影响指标使用效率。

此外，指标行政配置的民主运行机制亦存在不畅，指标制度涉及国计民生，关乎农民的切身利益，影响国家的发展进程，但指标运行机制中无论是土地利用规划还是土地转用的审批和监督管理，农民、集体及其他权利主体参与的机会都是少之又少，无论是指标的设定阶段还是指标的实施阶段，立法上都缺少相关利益主体参与程序的规定，而程序规定的缺乏也直接表明了缺乏对不同主体的利益诉求的有效回应。以土地规划权的行使流程为例，虽然《城乡规划法》第38条、第39条明确规定以合同的形式确定具体规划条件，但确定规划条件的名为合同，实际上却是由地方政府预先作出的行政决定，仍然表现为行政单方行为。

看似强势的管制措施并没有带来良好的指标运行效果，相反，过于严格的管制措施造成了指标行政配置的失灵。根据自然资源部2017年中国土地矿产海洋资源统计公报的数据显示，2017年发现土地违法案件7.52万件，涉及土地面积2.98万公顷，较2016年分别增长1.6%和10.7%。④

（二）市场在土地资源配置中作用

“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”是党的十八届三中全会在理论上的重大突破和实践上的重大创新，具有鲜明的时代特征，是深化经济体制改革必须紧紧抓住的主攻方向。市场机制可以有效促进资源投入的增加并增加每一单位投入的产出，促使资源在不同部门、不同地区之间合理优化配置。指标的市场机制激发了相关利益主体复垦整理的积极性，在减少农村闲置建设用地的同时增加城镇新增建设用地，增加了单位投入的产出，也促使土地资源在城乡之间，乃至东西部地区之间更加合理的配置。

由于指标行政配置的失灵，中央政府开始允许部分试点地区进行改革探索，各地在政策的指引下开始广泛进行指标市场交易探索。“增减挂钩”和“重庆地票”是实践中发展较为可取的两种市场模式探索：增减挂钩最初以项目为依托，周转指标仅允许在项目内使用，不得突破。2016年原国土资源部出台规范开展节余

② 参见安子明：《土地规划制度的权力结构分析——兼论以公民与人大为主导的土地规划模式》，载《中国土地科学》2013年第4期。

③ 参见汪晖、王兰兰、陶然：《土地发展权转移与交易的中国地方试验——背景、模式、挑战与突破》，载《城市规划》2011年第7期。

④ 《2017年自然资源公报》，载中国政府网，http://gi.mnr.gov.cn/201805/t20180518_1776792.html，最后访问时间：2020年6月22日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

指标省域范围内流转工作。为有效实现脱贫攻坚的战略目标,2018 年国务院办公厅发布《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》,扩大了增减挂钩的适用范围。同年,中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》,指出建立城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂机制,将所得收益通过支出预算全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略,拓宽资金筹集渠道。以重庆"地票"交易为代表的指标交易更好地体现了市场在资源配置中的决定性地位。"地票"交易是将农村闲置的建设用地、宅基地复垦整理为耕地,经相关行政主管部门验收合格后产生新增建设用地指标,并由主管部门向指标生产者发放凭证,通过政府搭建的农村产权交易平台进行指标交易,有意愿使用指标的主体可以在此平台内购得指标。⑤ "地票"交易模式实现了指标生产与落地的脱钩,赋予指标生产者与使用者自由选择权。

当前指标交易的缺陷主要在于市场化程度不高,从主体上来看,农民与集体作为直接利益者对指标交易的实际参与不够,难以真正掌握指标交易中的关键性因素。且指标交易的方式亦受到过多的行政干预,由于农民与集体缺乏必要的复垦资金,集体建设用地复垦的决定权实际上由政府掌握,指标交易平台由政府直接搭建,甚至在增减挂钩过程中地方政府直接作为交易主体获取指标,指标的落地同样需要政府实施土地出让行为。指标的财产价值属性没有得到立法者的承认,缺少法律保护使得其市场化程度无法突破。

三、建设用地指标法律属性的理论分歧

对法律属性作出科学定位,是开展制度研究和规范构造的前提与基础。学界在研究指标相关制度时亦对此问题表现出极大兴趣,但至今未能形成统一观点。总体而观,对于指标法律属性的界定可以从指标的不同运行状态作出简单分类。

(一)指标行政配置阶段法律属性解读

在这一阶段,指标被普遍地理解为一项管制工具。指标并没有被作为一项独立的研究对象在学界引发深入和广泛的研究,其解读基本蕴含于土地管理相关制度的研究之中。有从土地规划权入手,对指标属性作出解读,认为在我国土地管理实践中,新增建设用地指标是土地规划权行使的工具或手段,本质上是土地规划权。而这种规划权遵循的是"指标总量控制、统一分配、层层分解和指令性配额管制"前提下而给予地方政府的一种开源,是完全单一的公权力运行模式。在这一模式下指标的法律属性应被解读为公权力运行的工具或手段,私法或财产权的色彩较弱。"⑥亦有将农地开发许可权作为落脚点,揭示指标的"命令—服从"单一公法属性。农用地转用审批过程中,中央政府根据土地利用年度计划确定建设用地规模,再通过自上而下的方式"统一分配、层层分解",一直下达乡镇。下级地方政府取得新增建设用地指标后,意味着有权变更农用地用途管制,从事农地非农化开发。指标是通过行政权力分配取得的,下级政府在实施开发许可行为需要服从上级政府的指标管理要求。⑦ 有从土地利用规划和土地用途管制协调关系中对指标的法律属性作出定义,认为国家基于促进经济、社会和生态环境的协调发展,编制土地利用规划,确定建设用地的总量和年度增量,并要求各级政府和土地的实际使用主体严格按照规划所确定的土地用途和使用条件来实施土地开发行为。指标以此可以被认定为一项土地管理工具,既体现为土地规划权的行使,又表现为行政许可权的运用。

上述基于土地用途管制制度的解读,是基本符合指标实际情况的分析。按照法律属性分析的一般规则,行政配置的指标无论是主体还是内容,均具有浓厚的公法色彩,指标封闭运行于行政机关内部,其指令性计划管制将指标的法律属性体现为公权力的行使。但随着指标市场交易实践的不断发展,完全由公权力支配的指标难以体现农民及其他主体的利益,指标市场交易的积极性得不到有效调动,逐渐难以适应现实需求。指标要求被赋予新的含义,其法律属性随着市场在资源配置中决定性地位的彰显开始出现新的含义。

(二)指标市场交易实践阶段的法律属性分析

随着指标市场化实践的不断探索,以指标为独立对象的研究开始逐渐增加,城乡建设用地增减挂钩制度

---

⑤ 参见曾野:《从指标权交易到发展权交易——美国 TDR 制度对地票制度的启示》,载《河北法学》2016 年第 3 期。

⑥ 参见孙建伟:《城乡建设用地置换中土地指标法律问题研究》,载《法学评论》2018 年第 1 期。

⑦ 参见张先贵:《农地开发许可权市场化改革的法理逻辑——兼论私法的方式如何实现土地管理的目标》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2018 年第 4 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

和地票交易制度的研究中，均出现一系列对指标法律属性的全新诠释与解读，指标市场化程度的不断加深，也赋予不同模式下指标私法属性的思考。

在对城乡建设用地增减挂钩制度的解读中，周其仁教授强调城乡建设用地增减挂钩的基础是级差地租，由于工业化和城镇化的需求，城市周边建设用地价值大幅增长，但受指标指令性管控，城市周边面临着指标缺失，不能直接实施农地的非农转用，而农村却有着大量闲置的建设用地，将这些建设用地整理复垦为耕地，再将置换出来的国家既定建设用地指标以外的指标用于城市周边。依靠级差地租实现农村地区土地收益。[⑧] 另有观点认为，增减挂钩实际发生在地方政府之间，且地方政府支付给农民的相关费用及建设集中居住区的资金均来自于政府的土地出让收益，因此，增减挂钩指标在某种程度上可以被认定为支付转移。

重庆“地票”改革是指标市场化发展的另一项代表性实践，由于其市场化程度高于增减挂钩，且在成渝地区取得良好实践效果，引发理论届“地票”法律属性的激烈讨论。学界的观点主要有三种：一种是认为“地票”是指标的票据化，地票在本质上是一种指标，是一种可交易且能跨区域使用的新增建设用地指标。[⑨] 第二种是从地役权角度对“地票”法律属性作出解读，明确“地票”的用益物权属性，并以地役权天然的开放性将地票交易中的权利形态包容其中，很好地兼顾了不同主体的实际需求。将地票交易理解为地役权，可以为实践中地票的登记、转让及抵押等问题在现有法律中找到落脚点，有利于进一步推进地票交易的改革进路。[⑩] 第三种“土地发展权说”的讨论最为广泛和深入，有学者认为地票交易本质上接近美国的土地发展权转移制度，土地用途管制促成土地发展权的产生，所谓土地发展权是将土地变更为不同用途的权利，是对土地在利用上进行再开发的权利。[⑪] 重庆“地票”交易是中国的土地发展权转移与交易（transfer of development rights，TDR）实践。从“地票”交易的模式来看，农村集体建设用地通过复垦变成耕地，这个过程本质上是将农民对已经使用的土地发展权进行还原，使得地票发送区土地开发受到严格限制；然后，通过地票交易，这部分被还原的土地发展权转移到城镇建新区，使得地票接受区原耕地得以转化为城镇建设用地，获得更高开发强度，最终在耕地数量不减少的前提下，实现了农民和地方政府之间土地发展权的转移。[⑫]

指标的“票据化”是对地票交易现象的简单描述，对于指标市场化进程中法律属性可能出现的变化置若罔闻，按照传统指标的指令性特征，这里地票被理解为管制工具的交易。指标的法律属性仍然被认定为公权力。这种界定方式属于经验化、肤浅化的碎片认识，没有真正地穿透事物的本质，无法真正地描绘出地票交易的的法律性质，更遑论其权利义务以及法律规范适用的明确。而“地役权说”和“土地发展权说”均是从法学的权利义务角度对指标内涵作出的更深层次的解读，且在理论上均具有一定的落脚点，但这些观点只是从指标市场交易的角度作出分析，关注点在于指标交易过程中如何利用私权的方式来维护不同主体的利益，但这种解读的使用范围仅限于指标的城乡置换实践，单纯以私权来定性指标既不符合我国社会主义公有制国家的基本经济制度，也忽略了私权化后可能带来的高昂土地开发成本，是一种片面的解读方式。

四、建设用地指标法律属性的应然表达

对指标现实脉络的梳理及对指标法律属性学界争论的辨析，均是明确指标内涵，澄清其法律属性乱象的手段。指标法律属性的应然表达是建立在指标制度的实践基础之上的，只有对其在现实中的本质和功能加以明确才有可能从法学理论角度对其有准确的认识。

（一）公私合作理念的彰显

从上述分析来看，指标的法律属性具有一定的时代特征，单纯从公权或者是私权角度解读指标是不足以

⑧ 参见北京大学国家发展研究院综合课题组：《还权赋能：奠定长期发展的可靠基础》，北京大学出版社2010年版，第22－24页。

⑨ 参见黄美均、诸培新：《完善重庆地票制度的思考——基于地票性质及功能的视角》，载《中国土地科学》2013年第6期。

⑩ 参见黄忠：《地票交易的地役权属性论》，载《法学》2013年第6期。

⑪ 参见高波：《现代房地产经济学》，南京大学出版社2010年版，第56－57页。

⑫ 参见文兰娇、张安录：《地票制度创新与土地发展权市场机制及农村土地资产显化关系》，载《中国土地科学》2016年第7期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

涵盖其全部外延的,而指标法律属性长期以来的争议,从某种程度上是由大陆法系追求严谨体系的要求与时代发展不相适应所造成的,指标的性质从根本上看是由社会需要所决定的。故而,对社会需要的准确定位,方可在此基础上对某项权利进行准确定位。实际上,对法律属性的定位属于价值判断,而对于社会需要的定位则属于事实判断。因此,从逻辑上来看,准确的价值判断是建立在正确的事实判断基础之上的。

指标是公权力与私权利合作互补的结果,其本质属性体现为公权力与私权利的融合。事实依据可从三个层面展开:从公私权合作的理念来看,随着社会主义市场经济的发展,公私经济成分出现转化与融合,也导致不同利益的趋同与融合。在土地领域,土地使用权逐渐与土地所有权分化,土地使用权的流转使得私法权益得到关注,耕地的家庭联产承包责任制则将私法权益带入其中。毋庸置疑,指标制度需要兼顾私权主体的利益和国家本位的利益,个人本位与国家本位利益的融合,产生出一种独立于二者的第三种利益——社会本位利益,而指标的本质在于对这一利益的维护,这是指标制度的经济基础和根源所在。但由于市场机制的不充分,私权单方治理模式难以为继,而具备一定流动性的开放型社会中公权力难以避免断崖式风险,从调整方式来看,公权力所表现出的"集中"调整手段和私权利所代表的"自由"调整手段有机结合成了一种新型的调整手段,强制性与灵活性各具优势,合作以实现互补是其应有的内在理念。

(二)法规政策精神的贴合

基于相关政策精神的回应,自改革开发以来,市场在资源配置中的地位不断提升,十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对市场与政府的关系做出科学定位,"市场在资源配置中的决定性作用"及"更好地发挥政府作用"作为重大的理论和实践命题,将指导土地资源配置领域的改革。因此,优化指标制度中政府与市场的关系亦是当前指标制度改革的重要命题。合理界定政府与市场的职能边界,建立统一开放、竞争有序的指标市场,离不开指标中的公权力与私权利的转换与合作,实现共赢。将指标定性为公权与私权的融合是从法学角度对当前政策的有力回应。

从实践需求来看,指标私权属性旨在解决市场交易中指标配置问题及不同主体的收益分配问题,是维护农民与集体土地权益,建立兼顾国家、集体和个人的收益分配方式的重要路径。但指标的存在包含着国家对土地资源的保护及控制城市化发展进程的公法思维,具有浓厚的公权力色彩,受到公法规范的调整。在指标中,以土地规划权和土地用途管制权为代表的行政公权力和以土地发展权为表现形式的私权利是同时存在的,且二者并非是绝对对立的状态,而是相互依存。忽略任一因素的作用,指标制度将难以为继。指标制度得以运行正是这两种看似冲突的权利(力)相互影响又兼容并蓄的结果。将指标的法律属性定位于公私权融合,既符合公私权合作理念,又能够彰显政府与市场关系政策精神,亦能满足实践发展需求。

(三)现实发展需求的满足

基于指标的这一特殊定位,其制度规范需要保留公权力与私权利应有的界限,一方面,将土地规划权和土地用途管制权等权力纳入法治化运行轨道,公权力的强制性特征天然地会对私权利的行使产生影响,且指标私权属性的凸显源自于公权力对土地资源的规划、管理。因为如果没有规划和管制,土地权利人可任意进行土地开发行为,则指标的私法利益丧失。因此,土地的管制与其私权属性有着重要的关联,维持指标公权力行使的民主性和法治化一是维持指标公法运行机制的必然选择,二是保障其私法制度运行的重要手段。另外一方面,需要对指标的私权属性加以规范。自 1998 年《土地管理法》修订以来,耕地保护成为国家的重要任务,但单一的行政强制手段一直未能发挥出很好的作用,究其原因在于缺少各利益主体对耕地保护工作的积极参与,而从观念上认同指标的私权属性,为特定地区的农民与集体创造适宜的市场交易条件,辅之以充分开放的交易平台。让农民、集体及参与土地开发的其他主体能够在交易市场上获取指标,并承担相应的耕地保护任务。既为私权主体谋取了正当的利益,又以私权行使的方式完成指标制度保护耕地的目标。

指标的公私融合属性最初表现为土地规划权和土地用途管制权的实施需要兼顾私法权益,从私法角度加以变革,而以土地发展权为代表的指标私权则需要遵循所有权社会化的观念,吸收公法思维。随着公权私法化和私权社会化的不断发展,则是需要土地规划权与土地用途管制权等公权力与土地发展权相互融合。因此,指标的公私融合属性是动态的过程,社会现实需求的动态变化过程将在反映于指标的属性之中。

五、公私融合属性下指标权力—权利的规范

厘清建设用地指标法律属性并非问题的最终解决方案,发掘这一属性下指标权力与权利的规范,进而从

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

制度上解决指标行政配置的僵化和市场交易的不足才能最终解决问题，推动指标制度的改革与发展。

（一）指标配置公权的制约

由于土地资源的稀缺性，国家对于土地资源的管控将长期存在。土地资源的特殊性和稀缺性决定了其不可能像一般商品一样完全资本化，其作为生产资料的功能不容忽视。土地首先表现出生产价值，其次才表现出财产价值。[13] 基于我国所有制的根本要求和社会发展现实的需求，完全市场化的指标是不科学也是不合理的，针对土地用途的规划与管制是实现城镇化发展与耕地保护平衡的重要工具。

土地改革的不断推进赋予了指标更符合新时代背景的含义。党的十九大首次明确实行“空间用途管制”，《土地管理法》明确了空间用途管制的作用及地位，为空间用途管制的立法工作奠定基础。空间用途管制是对原有土地用途管制制度的发展与创新，标志着用途管制从平面的土地正式走向立体的空间、从割裂的单要素管制迈向“山水田林湖草”生命共同体的综合管制、从耕地和林地保护通向生态空间管制。[14] 从尊重发展需求的原则出发，由空间用途管制取代土地用途管制继续发挥对土地等资源的保护。空间用途管制将使土地及其他自然自然资源的规划更加具体化，且原来仅从平面进行用途管制的指标将逐渐发展至从立体角度全方位实施宏观控制，将对建设用地指标总量的控制转化为对容积率的管理。空间用途管制制度下，建设许可权、用途变更权及强度提高权共同构成指标的公权力外在表现。指标背后的行政权力在这一制度下有意识地相互协调和配合。指标是立法确立的一项重要土地调控工具，表现出以行政权为主导的本质特征。指标具有公权力属性主要体现在两个方面。

一方面是土地规划权的运行。我国的空间规划体系概念始于2013年，经历了两规合一、三规合一，发展至多规合一，并自2018年起正式展开空间规划体系的建构。空间规划体系将对现有的五级管理层级进行优化和分工，将国家和省级规划定位于战略性规划，将市、县规划确立为分解上级规划和实现城乡规划一体化的中坚力量，乡镇规划则作为上述规划有效整合与有力执行的具体实施。空间规划体系下不同层级的规划分工明确，可有效避免陷入上级规划任务繁重，下级规划仅起传达作用的困境。

另外一方面则是用途管制权的具体实施。国土空间用途管制的对象将不再局限于以基本农田保护为重点的耕地保护，而是进一步扩展到以生态保护红线划定为重点的水流、森林、草原等各类自然生态空间保护。以空间规划为依据的空间用途管制，针对不同层级的规划将采取不同的管制手段，随着层级的降低，管制的内容应愈加精细，可操作性越强，省级以下地方政府的管制权得到扩张。与此同时，占补平衡制度可能随之发生改变，目前所实施的占补平衡的基本要求是指标的“落地”必须完成建设所占用农用地（由其是耕地）相应规模和质量上的补充。而在未来，占补平衡制度将可能被运用于其他生态用地的保护，在发生占用其他各类生态用地时均需要做到占补平衡，这一制度将在空间用途管制下得到进一步发展。

建设用地指标配置制度的重塑首先需要打破单一的行政管制模式，并在此基础上对配置权力作出准确定位。指标配置权的基本实现方式为通过对建设占用农用地及未利用地做出限制，从本质上来看，这一权力是对土地开发利用相关权益的限制。[15] 其次，单一的公权力运行并不能实现指标配置，多项公权力的协调推进是指标配置背后基本的权力形态，其中包含土地规划权、土地用途转用权及开发许可权等多项权力。正确认识指标配置公权力需要对配置过程中涉及每一项权力的定位作出分析，分析这些权力之间相互作用形成的权力结构，从而实现指标配置权的重塑。如从纵向结构来看，需要打破原有的上级政府发布指令，下级政府负责执行的单一向度行政权运行原则，保障各级政府的指标配置权及其配置行政行为在目标上的一致性和对不同层级的指标配置权在功能上的区分性。从横向结构来看，则需要建立起指标配置中规划、管制等各项行政权力之间的协同关系。

（二）指标私权的法治化发展

随着社会主义市场经济的不断发展，指标开始出现市场化的变革，其中具有典型意义且有推广价值的主

---

⑬ 参见曾野：《从指标权交易到发展权交易——美国TDR制度对地票制度的启示》，载《河北法学》2016年第3期。

⑭ 参见黄征学、祁帆：《从土地用途管制到空间用途管制：问题与对策》，载《中国土地》2018年第6期。

⑮ 参见张先贵：《法教义学视角下我国土地用途管制权概念：重释与厘定——基于〈土地管理法〉修改背景下的审思》，载《河北法学》2019年第2期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要有城乡建设用地增减挂钩和重庆“地票”交易。市场机制的发展离不开明确的产权界定。增减挂钩和重庆“地票”交易制度均是通过复垦,将偏远地区的农地非农转用的权利通过交易平台转移到城郊地区,这项权利具有财产权稀缺性和独立性以及可交易的特点。可交易性是财产权的核心特征,而指标正是具有了这一核心要素而有资格成为财产权,拥有指标的主体可以在规范的限制范围内对指标进行处分,用于交易获取对等利益或者作为财产的一部分予以自行保留。以物权法的基本理论为切入点,这一项权利实际上是对土地的特定处分,那么当然地按照所有权理论,这一项权利可以被视为所有权权利束的一部分。吸收国内外对于土地发展权相关研究的理论,指标蕴含的私权与土地发展权的属性具有高度相似性。具体而言可以从主体、客体和内容三个层面展开论证。

首先,“正是基于主体制度,诸如权利、法律行为、责任等民事制度设计才能得以全面展开。法律的一切制度无不围绕着如何保护善意主体、惩戒恶意主体,协调主体之间、主体和社会之间的利益关系而设计。”⑯由于土地发展权的实际来源是土地所有权,因此,土地发展权主体可以被认定为指标输出区域的集体经济组织。由于我国农村土地所有权主体归属于集体,所有权的权能可以认定属于集体经济组织所有成员,土地发展权主体亦可以被认定为土地使用权人。从实践情况来看,重庆“地票”交易在其管理办法中对“地票”收益所作出的规定,基本印证了指标的权利主体是农村集体经济组织与农民。根据《重庆市地票管理办法》的规定,地票收益除缴纳少量税费外,绝大部分归农民家庭所有,地票价款扣除复垦项目工程成本和融资成本后,85%支付给退出宅基地的农户,15%归农村集体经济组织。但在增减挂钩制度中,权利的主体确是处于被忽视的状态,相关规定缺少对节余指标的物权规范。出现这一现象的主要原因在于增减挂钩基本是发生在不同地方政府之间的,其收益一般按照“收支两条线”来进行管理,农民与集体经济组织并不能直接获取的增减挂钩的收益,农民所获取的收益一般是以土地征收的形式发放的。

其次,权利的客体是立法者通过授予主体法律上的权利予以保护的利益的具体化。土地发展权不同于一般的土地使用权,分析《民法典物权编》对土地使用权的规定,土地使用权总是与特定宗地相联系并固化于该宗地,不能进行空间转移,土地使用的对象是具体的“土地”,它是一种“有体物权”。而由于土地发展权实现了空间上的转移,其权利指向的对象是开发容量而非土地本身。土地发展权不同于传统的土地权利,表现为抽象的无体物权,其权利的客体可以被认定为土地开发容量。土地开发容量体现为一项利益源于土地规划权和土地用途管制权的行使,由于国家严格限制农用地的非农转用,掌握特定地块的土地开发容量,即可以完成相应的建设用地开发活动。耶林认为“用益塑造了权利的实质,换言之,决定权利本质的所谓目的,乃是用益(利益)。”⑰因此,当土地开发容量所代表的利益在指标交易中不断显化,需要法治化的规范,通过立法的形式将利益逐渐上升为权益,最终成为一项权利。

最后,土地发展权的内容即是土地发展权的法律关系。指标行政配置过程中,土地发展权被土地规划权和土地用途管制权吸收,政府利用其规划管制的公权力将土地使用权转移给土地实际使用权人,在这一过程中,土地发展权跟随着土地使用权发生转移,因此其私权属性基本得不到体现。有学者将土地发展权分为两级,一级土地发展权隐含在中央政府对地方政府、上级政府对下级区域的新增建设用地许可中;二级土地发展权则隐含在地方政府对建设项目用地的规划许可中。⑱贴切地说明了行政配置过程中土地发展权的隐匿性。而指标的市场化改革探索则让其私权属性逐渐明晰,在现有的城乡建设用地增减挂钩和重庆“地票”交易中,土地发展权的基本形态开始逐渐显现并经由政府搭建的交易平台发生转移,指标交易直至落地,才将虚拟的土地开发容量与具体地块相结合实现权利的实化。通过土地发展权的市场交易将偏远地区的土地开发权利转移到城市近郊区。

将土地发展权作为一项独立的权利写入法律规范体系之中,基于上述分析将其定位于用益物权并从立法上加以明确规范。确定土地发展权的归属是保障权利主体行使权利、履行义务,实现定纷止争、确定财产

⑯　参见孙建伟:《土地开发权应作为一项独立的财产权》,载《东方法学》2018年第5期。

⑰　参见朱庆育:《意志抑或利益:权利概念的法学争论》,载《法学研究》2009年第4期。

⑱　参见林坚、吴宇翔、郭净宇:《英美土地发展权制度的启示》,载《中国土地》2017年第2期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

权制度运行秩序的基础。[19] 随着社会主义市场经济的不断发展，指标的市场化发展将不断推进，建设用地增减挂钩和重庆“地票‘交易将逐步走向更加合理的市场化指标交易形态，土地发展权的归属将进一步明晰，由土地权利人行使。从土地发展权的财产权定位来看，土地发展权来源于土地所有权，其归属问题与土地所有权的归属保持一致，即国有土地的发展权与集体土地的发展权分别归属于国家和集体。这一安排符合我国土地所有制的基本内涵，也是指标配置市场化发展的正当权利来源，且国家作为国有土地发展权的主体，表现为私权主体的身份，不能按照公权力主体的方式来经营土地发展权，避免政府依据自身行政职权对其他主体的土地发展权造成侵害。值得注意的是我国的国有土地使用权有偿出让合同一般都对土地的容积率作出具体要求，这土地发展权空间维度的具体表现。[20] 同样地，集体土地的发展权也不能局限于平面维度，在未来增减挂钩和重庆“地票”交易制度不断发展的过程中需要将立体维度的指标纳入交易范畴，更好地体现指标在立体维度上的权利和价值，以实现对土地发展权更加全面地保护。至于对立体维度土地发展权的法律规范，可以类推适用平面维度土地发展权的相关管理规范。

结论

从指标的实践出发，公权力和私权利同时存在于指标之中。且理论界对指标法律属性的争议中，指标在行政配置中将公权力作为法权表达是毋庸置疑的，而在指标的城乡置换改革实践中，指标所表现出的私权属性也在学界达成一定的共识。指标法律属性解读的主要缺陷在于忽略了不同类型指标共存的现实，从而导致解读的片面性。指标法律属性的应然表达是承认指标所蕴含的公权属性与私权属性，从指标的现实需求来看，指标具有公私权融合的属性，这一属性是公私权合作理念的彰显，亦是对政策精神的回应，更是指标实践现实的法学诉求。指标这一特殊的属性定位要求其制度规范既要保留公权力与私权利之间的合理界限，又要以动态的目光来衡量指标法律属性的发展与变化。在此基础之上，对指标的公权与私权加以法治化规范，重新诠释土地规划权和用途管制权在空间用途管制改革中的内容与价值，论证土地发展权逐渐独立于土地所有权的事实依据，阐明指标交易的法学表达是土地发展权交易。指标法律属性的解读是重构指标法律制度的起点，关乎指标配置的方式及配置效率的高低，明确其法权表达一方面保障了指标理论基础的系统性，与指标适用的法律原则相互印证，另一方面，指标的法律属性对于引领实践发展具有重要价值，指导指标运行相关规则的制定。因此，正确界定其法律属性的内涵与外延，是实现理论与实践目标统一的有效路径。

Abstract: The marketization reform of construction land index is widely carried out in practice. Based on the rigid administrative allocation of construction land index and the obvious role of market in land resource allocation, it is necessary to reinterpret its legal attribute. At present, the academic circle has both the "private right theory" and the "public right theory" on the basis of the basic theoretical proposition of the legal property of construction land index, which presents a chaotic and one-sided situation which needs to be clarified. Starting from the social reality, the construction land index is an important land control tool of the state, with the external manifestation of public power, and also participates in the market transaction, showing the appearance of private rights. Its legal attribute needs to be compatible with the two, and it should be positioned as the attribute of public-private right integration conforms to the concept of public-private right cooperation in concept, conforms to the spirit of policies and regulations in standard, and meets the practical development needs in practice. Based on this, the author sets reasonable limits on the public power, such as the land use control right, and legislates and standardizes the private property of the land development right.

Key Words: Construction Land Indicators; Legal Attribute; Power; Private Right

（责任编辑：孙 晋）

[19] 参见刘剑文、王桦宇：《公共财产权的概念及其法治逻辑》，载《中国社会科学》2014年第8期。

[20] 参见汪莉、彭婷婷：《从静态模式到动态分析：建设用地指标法律属性探析》，载《江淮论坛》2017年第2期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net